

1502446-29.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502446-29.2021.8.26.0530

Controle: 2021/002329

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295846/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉSSICA SOUZA DA SILVA

Aos 20 dias do mês de julho de 2022, às 13:30 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. EDUARDO LUIZ MICHELAN CAMPANA; a ré Jéssica Souza da Silva, seu Defensor constituído, Dr. JAN RENATO BRAZ GOUVÊA (OAB/SP 310452); COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: as testemunhas arroladas pela acusação Policiais Militares André Gustavo de Souza e Matheus Arantes Rosa. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela acusação Policiais Militares André Gustavo de Souza e Matheus Arantes Rosa, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir o MM. Juiz interrogou a ré Jéssica Souza da Silva, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no

sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

Vistos.

JÉSSICA SOUZA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 20h00, na Avenida Elizeu Tamião nº 155, nesta cidade de comarca de Sertãozinho, trazia consigo e transportava 4,18 Kg (quatro quilos e dezoito decigramas) de cocaína, acondicionados em 04 (quatro) invólucros constituídos por fitas adesivas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação preliminar de fls. 11, fotografia de fls. 12, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 92/94, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, a acusada, no exercício da atividade ilícita, transportava na motocicleta Honda/CG 125 FAN KS, placa FBE4746, 04 (quatro) tijolos de cocaína. Ocorre que, quando transitava pela via pública acima mencionada, Jéssica foi parada por policiais militares que realizavam abordagem rotineira pelo local. Durante a abordagem, acabou revelando aos policiais que estava carregando drogas em sua mochila. Diante disso, os agentes policiais revistaram a mochila e encontraram em seu interior os 04 (quatro) pacotes de cocaína. Indagada a respeito, Jéssica confessou que foi contratada por uma pessoa não identificada para transportar o entorpecente até o bairro Alto do Ginásio, após pegá-lo em uma esquina no Bairro Vila Aurea, e que, pelo serviço prestado, receberia a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 105/106), a ré foi citada (fls. 114) e apresentou resposta à acusação (fls. 122/123).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns às partes, sendo a ré interrogada ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da acusada, nos termos da denúncia.

A Defesa da acusada requereu o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, da atenuante da confissão espontânea, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo auto de constatação preliminar (fls. 13), pela imagem fotográfica de fls. 14, pelo laudo químico-toxicológico (fls. 94/96), conclusivo por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e segura.

As testemunhas policiais militares André e Matheus, tanto na fase policial quanto em Juízo, declararam que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e procedimento de bloqueio quando avistaram Jessica conduzindo uma motocicleta, momento em que resolveram fazer uma abordagem rotineira e aleatória. No entanto, ao pararem-na, após pedirem os documentos, ela de imediato afirmou que estava carregando drogas em sua mochila. Ato contínuo, ao revistarem a mochila da acusada, encontraram os entorpecentes mencionados, a tratar-se de 5 tijolos de cocaína. A ré não trazia dinheiro consigo. Segundo a testemunha Matheus, a ré disse que transportava a droga para terceira pessoa e ganharia R\$ 50,00 pelo serviço (fls. 05, 06 e mídia).

A ré, na fase policial, declarou ser a primeira vez que transportava algo ilícito. Que, à data dos fatos, pegou uma mochila em uma esquina no bairro Vila Aurea e iria

transportá-la até as proximidades da pista na saída do bairro Alto do Ginásio. Contudo, foi abordada em um bairro que não sabe o nome, pelos policiais militares, e foi confessa, de pronto. Por fim, disse não saber da pessoa que a entregou a mochila com a droga e muito menos quem iria recebê-la no ponto de entrega, afirmando apenas que ganharia pelo ato o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). (fls. 06). Em Juízo, admitiu que realmente transportava a droga entre dois bairros de Sertãozinho, para pessoa cuja identidade não quer revelar, quando foi abordada pelos policiais, e ganharia R\$ 450,00 pelo serviço. Alega que era a primeira vez que fazia esse tipo de serviço, e assim agiu porque precisava de dinheiro. Mora com seus dois filhos pequenos e ainda está grávida (v. mídia). Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão. Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que a acusada portava a droga apreendida, a qual se destinaria à comercialização. Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais, durante patrulhamento e fiscalização de rotina, visualizaram a acusada e decidiram realizar a abordagem.

Em seguida, sem que fosse necessário proceder à revista pessoal, Jéssica confessou que estava transportando entorpecentes em uma mochila, momento em que, ao revistarem tal mochila, encontraram 04 (quatro) tijolos de cocaína em seu interior. Não bastasse, a ré confessou que realmente transportava a droga para terceira pessoa. Segundo esclareceu, a droga apreendida pertencia a terceira pessoa, sendo que a entregaria para pessoa desconhecida, a qual lhe pagaria R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por tal serviço.

Ainda que se considere verdadeiro o relato da ré, é certo que tal conduta de transportar droga para consumo de terceiros é também considerado tráfico, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, não prospera a tese apresentada pela ré de que agiu acobertada por causa de inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade. A inexigibilidade de conduta diversa ou mesmo o estado de necessidade são matérias que devem ser comprovadas pela Defesa (CPP, art. 156) e não foram demonstrados nos autos, não bastando a mera alegação de que estaria passando por necessidade financeira para justificar sua conduta ilícita.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação da ré como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que a acusada é confessa, contudo, considerando que tal fator não tem o condão de reduzir sua pena além do mínimo, permanece a pena fixada na primeira fase (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os

mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas,

incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, notadamente considerando a grande quantidade de droga apreendida na posse da ré (5 tijolos de cocaína), reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime.

Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré JÉSSICA SOUZA DA SILVA, qualificada nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade.

Declaro a perda, em favor da União, da motocicleta apreendida nos autos (Honda/CG 125 FAN KS, placa FBE4746), vez que há prova segura de que foi utilizada para a prática do tráfico, nos termos do art. 61 e seguintes da Lei 11.343/06, ao menos se exigindo a legislação que tal uso seja habitual (v. “caput” do art. 61) ou que haja pedido específico na denúncia, observando que, no caso em tela, tal pedido foi formulado na mesma oportunidade em que a denúncia foi oferecida (v. fls. 101).

Em face da condenação, a ré arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência

judiciária gratuita.

Pela Ré, seu Dr. Defensor e pelo Promotor de Justiça foi dito irão se manifestar dentro do prazo. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Aguarde-se eventual interposição de recurso por parte da Defesa e por parte do Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Oficie-se o necessário.

Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais."

Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.